Tópico 08

Administração e Aspectos Legais

Direito Empresarial II

1. Introdução

Sociedade é um termo com diversas aplicações e pode significar coisas distintas, dependendo da área que o tiver estudando. No nosso dia a dia, usamos diversas aplicações desse termo, a começar pela forma como nos organizamos, afinal de contas, **vivemos em sociedade.**



O estudo da organização social cabe especialmente à Sociologia, muito embora seja ele essencial para inúmeras, senão todas, as demais áreas de conhecimento. No Direito, esse conceito de sociedade é primordial, tendo em vista que a finalidade do Direito é justamente regulamentar as relações sociais.

Contudo, há ainda um outro conceito de sociedade que é muito importante para o Direito, em especial, para o Direito Empresarial. Estamos falando do conceito de sociedade formada para o desempenho de atividades empresariais – a sociedade empresarial.

Quem resolve abrir um negócio, tem de decidir se empreenderá sozinho, ou se contará com um sócio para dividir os riscos e consequentes lucros da empreitada. Isso pode ocorrer naquele pequeno negócio de venda de doces até um grande empreendimento imobiliário, passando por diversas formas de organização social da atividade empresária.

Assim, neste tópico, veremos as vantagens e desvantagens de se exercer a atividade empresarial em sociedade para que você tenha ferramentas aptas a lhe auxiliar na

decisão da melhor forma a ser adotada no seu empreendimento profissional. Vamos lá?!

2. Pessoa Jurídica e Sociedade

Para o Direito, o conceito de pessoa não se confunde com o de ser humano. Lidamos com as pessoas físicas – seres humanos de carne e osso, como eu e você – e com as pessoas jurídicas – ficção criada pelo Direito, pois, no mundo real, essas pessoas não existem, não conseguimos ver, nem tocar uma pessoa jurídica, sua existência está restrita ao plano das ideias e à regulamentação legal dada a ela.

Contudo, não é porque não existem no mundo real, que as pessoas jurídicas deixam de ser importantes, ou possuem importância reduzida. Pensemos, por exemplo, nas atividades administrativas de nosso país. Quando necessitamos de um benefício previdenciário perante o INSS, ou quando temos alguma pendência a ser resolvida na Receita Federal, lidamos com pessoas físicas, os servidores que nos atendem, mas tais pessoas atuam em nome da pessoa jurídica que representam. A nossa relação é travada com essas pessoas jurídicas, as pessoas físicas apenas funcionam como intermediários nessa relação.

Nos exemplos dados, estamos falando das pessoas jurídicas de Direito Público. No nosso estudo, interessa-nos as pessoas jurídicas de Direito Privado, ou seja, aquelas pessoas criadas pelo Direito e que se fazem presentes nas relações travadas entre particulares.

O art. 44 do Código Civil (BRASIL, 2002) enumera quais são essas pessoas:

> *Art. 44. São pessoas jurídicas de direito privado:*
>
> *I – as associações;*

> *II – as sociedades;*
>
> *III – as fundações.*
>
> *IV – as organizações religiosas; (Incluído pela Lei nº 10.825, de 22.12.2003)*
>
> *V – os partidos políticos. (Incluído pela Lei nº 10.825, de 22.12.2003)*
>
> *VI – as empresas individuais de responsabilidade limitada. (Incluído pela Lei nº 12.441, de 2011) (Vigência).*
>
> *(BRASIL, 2002)*

As pessoas jurídicas são criadas para os mais diversos fins – filantrópicos, sociais, educacionais, políticos, religiosos, ou econômicos. A depender do fim perseguido, será criada uma pessoa jurídica específica. Interessa-nos um tipo singular de pessoa jurídica, as sociedades.

Como em todas as espécies de pessoa jurídica, as sociedades não se confundem com as pessoas físicas que a compõem e, como veremos, esse pode ser o maior interesse em se constituir uma sociedade, já que o patrimônio dela não se confunde com o patrimônio de seus sócios. Por exemplo, se quatro pessoas se reúnem e criam uma sociedade, temos cinco patrimônios, o patrimônio particular de cada uma delas e o patrimônio da sociedade.

Mas, afinal, o que é sociedade? De acordo com o senso comum, costumamos denominar sociedade qualquer reunião de duas, ou mais pessoas, com uma finalidade específica. Se essa reunião de duas, ou mais pessoas, decorrer de um acordo de vontades, com reunião de investimentos e se a finalidade específica for lucrativa, temos o conceito de sociedade.

Acordo de vontades + reunião de investimentos + duas, ou mais pessoas + fins lucrativos = sociedade

É importante deixar claro, desde já, que essa reunião de investimentos não precisa ocorrer de modo igualitário, ou seja, não é necessário que cada sócio contribua exatamente com o mesmo valor. Nem mesmo se faz necessário que todos contribuam financeiramente. Pode, por exemplo, um sócio investir o capital e o outro a mão de obra, ou algum outro tipo de investimento intelectual, ou de serviço.

Segundo o conceito da doutrina:

> *"Podemos conceituar a sociedade como a entidade resultante do acordo de vontade de duas ou mais pessoas que se comprometem a reunir capital e trabalho para a realização de operações com fins lucrativos. Se a sociedade realiza seu registro no órgão competente, torna-se, então, pessoa jurídica".*
>
> *(CHAGAS, 2017, p. 157)*

Do conceito apresentado por Chagas (2017, p. 157), podemos extrair que não necessariamente toda sociedade será uma pessoa jurídica. Vocês se lembram que conceituamos pessoas jurídicas como uma ficção jurídica? Pois bem, se se trata de uma ficção, ela requer algum tipo de formalidade para que tenha uma existência válida. É por isso que o autor menciona que será pessoa jurídica a sociedade devidamente registrada no órgão competente. Logo, é possível a existência de sociedade sem a correspondente pessoa jurídica. Falaremos mais sobre o assunto no próximo item.

3. Sociedade Personificada e Sociedade

Não-Personififcada

Nosso estudo preocupa-se, especialmente, com as sociedades empresariais. Em sua maioria, tais sociedades são também pessoas jurídicas, ou seja, são sociedades personificadas. Todavia, existem sociedades empresariais que não constituem uma pessoa jurídica, por não terem se registrado no órgão adequado. Estamos falando das sociedades não-personificadas.

Essa ausência de personificação própria da sociedade, ou seja, a ausência da pessoa jurídica, pode decorrer de situação transitória, ou não. Isso se deve, porque, a partir do momento em que já se têm presentes os requisitos caracterizadores da sociedade (acordo de vontades + reunião de investimentos + duas, ou mais pessoas + fins lucrativos), já se fala que ela existe, mesmo que seus sócios ainda não tenham efetivado o registro nos órgãos competentes. Por outro lado, há sociedades criadas sem a intenção de promover o registro, mantendo-se na informalidade.

Portanto, temos duas situações: a inexistência de qualquer documento formal escrito que comprove o pactuado pelos sócios, ou a existência do documento, geralmente um contrato, que não foi levado a registro (sociedades de fato), ou foi registrado no órgão incorreto (sociedade irregular). Em ambos os casos, temos a chamada **sociedade em comum.**



Exemplo comum de sociedade de fato são os negócios familiares. Quando os membros de uma família se reúnem, a fim de produzir e vender marmitas saudáveis, sem redigir nenhum documento com os termos do acordo, temos uma sociedade de fato, espécie do gênero sociedade em comum.

Ou, quando dois amigos decidem montar uma carrocinha de cachorro-

quente, elaborando um “contrato de gaveta” sobre o acordado, também temos uma sociedade de fato.

A sociedade irregular existe, quando o registro se dá no órgão errado. Exemplo comum é a sociedade de advogados, que obrigatoriamente deve ser registrada em uma Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, cujos sócios a registram na Junta Comercial. A sociedade não perde a sua existência, porém, essa existência não atende aos critérios formais de validade.

É importante ressaltar que a ausência de registro não torna a sociedade ilegal, desde que seu objeto seja lícito. Contudo, realizar o registro, constituindo, portanto, uma pessoa jurídica, autônoma em relação às pessoas físicas que integram a sociedade, traz consequências importantes e positivas para os sócios. Isso porque, no momento em que a sociedade passa a ter existência autônoma de seus sócios, ela passa a titularizar direitos e a ter deveres, respondendo pelo empreendimento.



Um empreendimento familiar, na maioria das vezes, ocorre sem que haja o devido registro nos órgãos competentes. Imagine o caso de duas irmãs que começam a realizar serviços de consertos de roupas para a vizinhança e, ao ver o retorno financeiro do empreendimento, expandem seus negócios, confeccionando peças e vendendo pelas redes sociais. É o tipo de sociedade que se inicia sem planejamento e, em consequência, não costuma ser formalizada através de um contrato registrado.

Assim, os sócios deixam de responder particularmente pelo empreendimento empresarial. Caso, por exemplo, o negócio fracasse, não será possível aos credores buscar a satisfação de seus créditos no patrimônio particular do sócio, mas tão somente no patrimônio da sociedade.

Sendo assim, podemos apontar como principais consequências de se atribuir personalidade jurídica própria à sociedade:

1. **Titularidade negocial:** é a sociedade quem realiza negócios jurídicos – compra de matéria prima, contratação de pessoal, assinatura de contratos e assinatura de títulos de crédito;
2. **Titularidade processual**: em caso de ação processual proposta pela sociedade, ou em

seu desfavor, é ela quem figurará em um dos polos da demanda, já que é ela quem realiza negócios jurídicos, contraindo obrigações;

3. **Responsabilidade patrimonial:** a sociedade possui um patrimônio próprio, distinto do patrimônio de seus sócios. Por isso, o que assegura as obrigações contraídas pela sociedade é o seu próprio patrimônio. Caso seja necessário demandar contra sociedade, os bens que assegurarão eventual condenação são os bens próprios da pessoa jurídica, e não os bens de seus sócios.

Mais à frente, trataremos dos tipos societários, dentre eles, os tipos correspondentes às sociedades não-personificadas: a sociedade em comum e a sociedade em conta de participação.

4. Sociedade Simples e Sociedade Empresarial

Dissemos que a união de vontades de duas, ou mais pessoas, com consequente reunião de investimentos e finalidade lucrativa, constitui uma sociedade. Tendo tal conceito em mente, precisamos, agora, distinguir a sociedade dita empresarial da sociedade simples.

De início, poderíamos dizer que será empresarial a sociedade que exercer atividade empresarial. É mais ou menos neste sentido que o art. 982 do Código Civil dispõe:

> *Art. 982. Salvo as exceções expressas, considera-se empresária a sociedade que tem por objeto o exercício de atividade própria de empresário sujeito a registro (art. 967); e, simples, as demais.*
>
> *Parágrafo único. Independentemente de seu objeto, considera-se empresária a sociedade por ações; e, simples, a cooperativa.*
>
> *(BRASIL, 2002).*

Portanto, analisando o *caput* do art. 982, podemos dizer que é sociedade empresária

aquela que exerce atividade econômica sob a forma de empresa, entendendo-se por empresa o que está disposto no art. 966 do CC/2002 (atividade econômica organizada, exercida de modo profissional, para a produção e circulação de bens e serviços). Em sentido contrário, seriam simples todas as sociedades com fins lucrativos cuja atividade não seja voltada para a produção e circulação de bens e serviços.

A primeira observação que deve ficar muito clara para nós é a de que não é a finalidade lucrativa que distinguirá a sociedade empresária da sociedade simples. Isso porque, conforme vimos no conceito do instituto, toda sociedade possui finalidade lucrativa. A principal distinção entre ambas é a forma de se exercer a atividade. Se a atividade principal desempenhada pela sociedade constitui elemento de empresa, trata-se de sociedade empresária; se não constitui, trata-se de sociedade simples.

No entanto, não podemos analisar o caput do artigo supracitado sem analisar, em conjunto, o disposto no seu parágrafo único. O parágrafo único do art. 982 do CC/2002 apresenta exceções à regra distintiva da sociedade empresarial e da sociedade simples. Veja, menciona o dispositivo legal que, independentemente do objeto, será sempre considerada sociedade empresarial a sociedade por ações.

Trataremos mais à frente da sociedade anônima, principal exemplo de sociedade por ações e ficará evidente o que motivou a opção legislativa. Como veremos, as sociedades por ações são deveras complexas e cheias de peculiaridades, o que vai na contramão da ideia de sociedade simples, justificando-se, assim, a impossibilidade de tais sociedades se organizarem sob a forma de sociedade simples.

Por outro lado, será sempre simples a sociedade cooperativa. Nesse caso, a escolha do legislador decorre do fato de que, nas cooperativas, o exercício da atividade de produção, ou circulação de bens e serviços, não se dá pela própria sociedade, mas por seus cooperados. Quem exerce atividade típica de empresa é cada cooperado e não a sociedade. Essa circunstância se encaixa perfeitamente no conceito de sociedade

simples.

Fiquemos com dois exemplos para melhor elucidar a questão:



Imagine uma cooperativa de taxistas. Esse tipo de sociedade existe, com o intuito de facilitar o exercício da atividade típica de empresa (produção, ou circulação de bens e serviços) por parte de seus cooperados. Quem exerce, de modo profissional e organizado, a atividade de produção e circulação de serviços é o taxista, não a cooperativa. Sendo assim, uma sociedade simples.

Agora, pensemos em um escritório de advocacia. A atividade exercida pelos sócios não é atividade empresarial, mas atividade intelectual. A formação da sociedade, muito embora tenha fins lucrativos, não tem presentes os elementos caracterizadores de uma sociedade empresarial, pois a atividade principal é a atividade intelectual. Por isso, uma sociedade simples.

As cooperativas de taxi existem, com o intuito de facilitar o desempenho da atividade empresarial por parte dos cooperados, mas elas mesmas não exercem atividade típica de empresa.

É neste sentido que a doutrina estabelece:

> *Na compreensão do Código Civil, as sociedades empresárias são aquelas que têm por objeto o exercício de atividade própria de empresário sujeito a registro (artigos 966 e 967); as demais são consideradas sociedades simples. Portanto, a nota distintiva da sociedade simples seria a inexistência de uma organização de bens materiais e imateriais (intelectuais), bem como de recursos humanos, voltada para a produção sistemática de riqueza. É o que se passa com algumas sociedades de profissionais liberais, nas quais cada um dos sócios desempenha, isolada e independentemente, por força da lei (ex vi legis) ou em virtude da vontade (ex voluntate), o objeto social.*
>
> *(MAMEDE, 2018, p. 25).*

Portanto, é sociedade empresarial "[...] a pessoa jurídica de direito privado não estatal, que explora empresarialmente seu objeto social ou adota a forma de

sociedade por ações” (COELHO, 2016, p. 68).

5. Classificação de Sociedades

Antes de adentrarmos no estudo específico de cada tipo societário, é importante conhecer algumas classificações das sociedades, pois esse conhecimento auxiliará, quando formos tratar de cada tipo de sociedade.

Já vimos duas classificações de sociedades, **quanto à personalidade jurídica e quanto à natureza jurídica.**

Quanto à personalidade jurídica, vimos que a sociedade pode ser **personificada**, ou **não-personificada.** Personificadas são as sociedades devidamente registradas nos órgãos competentes, criando uma pessoa jurídica autônoma em relação às pessoas de seus sócios. Por outro lado, temos as sociedades não-personificadas, situação na qual não temos a criação de pessoa jurídica, ou por total ausência de registro, ou por registro em órgão incompetente.

Vimos também a classificação **quanto à natureza jurídica das sociedades,** através da qual temos **sociedades empresárias** e **sociedades não-empresárias (sociedades simples).** São empresárias as sociedades cujo objetivo principal é o desenvolvimento da empresa – atividade profissional, exercida de modo organizado, para a produção e circulação de bens e serviços – e as sociedades por ações. De outro lado, são sociedades simples todas as demais.

Importa, ainda, vermos a classificação **quanto ao ato constitutivo e quanto à pessoa dos sócios.**

Quanto ao ato constitutivo, temos sociedades cuja formação decorre de um **contrato social** e cuja formação decorre de um **estatuto social.** O ato constitutivo é o instrumento que oficializa a existência da sociedade.

O **contrato social** expressa o acordo de vontades ao qual chegaram os sócios. Geralmente, são constituídas por contrato social as sociedades de menor complexidade, pois o contrato consegue expressar de modo mais fidedigno a vontade dos sócios. Ao elaborar o contrato, os sócios têm mais possibilidade de discutirem suas cláusulas e acordarem conjuntamente como será regida a sociedade. Já a constituição da sociedade por **estatuto social** ocorre, via de regra, nas sociedades mais complexas, tais como a sociedade anônima. Na sociedade regida por estatuto, não há tão firme a presença da vontade dos sócios na sua elaboração. A aprovação se dá em assembleia, no termo do estatuto não consta a qualificação dos sócios. Isso tudo demonstra a maior complexidade das sociedades regidas por estatuto social.

Observe no vídeo a seguir as informações essenciais que devem constar no ato constitutivo da sociedade e quais são os passos para o devido registro:

No que se refere à pessoa dos sócios, temos sociedades de pessoas e sociedades de

capitais. Quando nos referimos à sociedade de pessoas, tratamos daquelas sociedades nas quais as pessoas que a formam possuem grande importância no desempenho da atividade empresarial. O acordo de vontades necessário à criação da sociedade envolve especificamente aquelas pessoas, as quais participarão ativamente no exercício da atividade-fim da sociedade. Há um termo que define essa importância das pessoas: affectio societatis, ou seja, a aptidão, ou desejo de exercer a atividade em conjunto. Nestas sociedades, não é possível a entrada de novos sócios sem a aprovação dos demais. Já na sociedade de capitais, a pessoa dos sócios não se mostra relevante para o desempenho da atividade, mas somente o capital que investem na sociedade. Neste tipo de sociedade, cada sócio responde apenas pelo valor que investiu e não há restrições quanto à entrada de novos sócios.

Na sociedade de pessoas, o foco está em quem exerce a atividade empresarial, deve existir a *affectio societatis* entre os sócios. Já na sociedade de capitais, apenas importa o capital investido por cada sócio, sendo indiferente a pessoa de cada um deles.

Portanto, podemos resumir a classificação das sociedades na seguinte tabela:

6. Tipos Societários

No decorrer deste tópico, falamos de alguns tipos societários, tais como a sociedade em comum e a sociedade simples. Debruçaremos, agora, de forma mais detida sobre cada um desses tipos.

O CC/2002 enumera mais de dez tipos societários. Nós não falaremos de todos eles. A ideia é aprofundarmos no estudo daqueles mais comuns e que possuem maior probabilidade de serem usados no exercício de sua atividade profissional no futuro.



Muito embora alguns tipos societários tenham regulamentação específica em lei especial (Lei das S/A por exemplo), o Código Civil de 2002 trata de forma muito completa do tema das sociedades em seu Livro II, Título II, Da Sociedade, dos arts. 981 a 1.141. Vale a pena a leitura dos dispositivos legais: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406compilada.ht

m

Falaremos dos seguintes tipos societários: sociedade em comum, sociedade em conta de participação, sociedade simples, sociedade limitada e sociedade anônima.

Sociedade em comum (art. 986 a 990, CC/2002)

Já sabemos que a sociedade em comum integra o gênero das sociedades não-personificadas, ou seja, trata-se de uma espécie de sociedade na qual seus sócios não procederam ao devido registro no órgão competente. Como vimos, não foi criada a pessoa jurídica, autônoma em relação aos sócios, titular de direitos e deveres.

A sociedade em comum ocorre nos negócios informais, quando não há nenhum tipo de documento escrito formalizando a relação jurídica, ou quando, apesar de existente, o documento não foi levado à registro. Também ocorre, quando o registro da sociedade é feito em órgão incorreto.

Como exemplo de sociedade em comum por ausência de registro, demos as sociedades familiares – constituição de sociedade para venda de marmitas, realização de serviços de costura, carrocinha de cachorro-quente. E como exemplo de sociedade em comum por registro no órgão incorreto, a sociedade de advogados que se registra na Junta Comercial, ou que tão somente registra o contrato social no Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas, deixando de efetuar o registro junto à OAB, descumprindo, assim, requisito obrigatório instituído pela Ordem.

Também serão regidas pelas normas aplicáveis à sociedade em comum as sociedades que pretendem ser sociedades personificadas, enquanto não ocorrer o registro. Desde o momento em que os sócios acordam suas vontades e passam a praticar atos preparatórios para o início das atividades, já existe a sociedade. Entre este momento e o efetivo registro, rege-se a sociedade pelas regras da sociedade em comum, excetuada a sociedade por ações, que possui regulamento próprio para este período,

conforme disposto na Lei das S/A – Lei 6.404/76.

A ausência do registro da sociedade gera duas consequências principais, a primeira delas é quanto à prova da existência da sociedade e a segunda quanto à responsabilidade dos sócios pelas obrigações decorrentes da atividade.

A prova da existência da sociedade pode se tornar problemática em duas situações: primeiro, na relação entre a sociedade e terceiros; segundo, na relação entre os sócios. A primeira situação se subdivide, ainda, em duas: a prova da sociedade por parte dos terceiros que, de alguma forma, se relacionaram com a sociedade e pretendem contra ela demandar; a prova da sociedade por parte dos sócios, nas relações que mantiverem com terceiros (MAMEDE, 2018, p. 28).

Vejamos a solução legal para cada uma dessas situações:

- Em se tratando da relação da sociedade com terceiros e, sendo este terceiro quem necessite demonstrar a existência da sociedade, poderá ele usar de qualquer meio lícito para tal. É o que dispõe o art. 987 do CC/2002, além do art. 75, IX e §2º do CPC/2015, que proíbem aos sócios usarem de sua irregularidade contra terceiros. Somado a isso, o art. 990 do CC/2002 estabelece que todos os sócios respondem de forma solidária e ilimitada pelas obrigações sociais, ou seja, pode o terceiro buscar a satisfação de seus créditos no patrimônio particular de qualquer um dos sócios. A única coisa que os sócios podem reivindicar é que se respeite o benefício de ordem, ou seja, que primeiro se busque a satisfação através do patrimônio particular da sociedade. Mas está excluído desse benefício o sócio que se obrigou em nome da sociedade;
- A segunda situação a ser analisada é quando os sócios precisam provar a existência da sociedade nas relações que mantiveram com terceiros. Neste caso, os sócios necessitam de prova escrita, ainda de acordo com o art. 987 do CC/2002. O documento exigido pela lei é documento em sentido amplo, não requerendo maiores formalidades. Assim, um recibo emitido em nome da sociedade já pode

ser usado como indício de prova de que o terceiro sabia da existência da sociedade. Segundo a doutrina de Gladston Mamede (2018, p. 28):

> *Se não há prova de que o terceiro tinha conhecimento da existência da sociedade, o contrato havido entre os sócios será res inter alios acta (coisa havida entre outros) para aquele. Assim, se o terceiro relacionou-se com um ou mais sócios determinados, sem saber que atuavam no âmbito de um contrato de sociedade, não poderá ser demandado por sócio com quem não se relacionou. A demanda deverá ser estabelecida entre aquele ou aqueles que estabeleceram, de fato e de direito, a relação com o terceiro. MAMEDE (2018, p. 28)*

- Por fim, na relação entre os sócios, apenas por escrito poderá ser provada a existência da sociedade, também de acordo com o art. 987 do CC/2002.

A outra consequência decorrente da ausência de registro da sociedade em comum é a inexistência de patrimônio em nome da sociedade. Ora, se não houve a constituição de uma pessoa jurídica, apta, portanto, a adquirir bens em nome próprio, o patrimônio da sociedade ficará em nome dos sócios. Daí decorre a obrigação solidária e ilimitada pelas dívidas da sociedade.

No entanto, é possível vislumbrar que a sociedade em comum possui um patrimônio especial que, muito embora esteja sempre no nome de um dos sócios, pertence ao empreendimento. Em virtude disso, dizemos que a sociedade em comum possui um patrimônio particular do qual os sócios são titulares em comum.

Sendo assim, quanto ao patrimônio ativo (bens e faculdades), os sócios são titulares em comum. Quanto ao patrimônio passivo (dívidas), os sócios responsáveis são solidários, ou seja, respondem conjuntamente pelas obrigações da sociedade.

Ao analisar as regras aplicáveis à sociedade em comum, é notório concluir que a regularização da sociedade é vantajosa para os sócios, pois, a partir do momento em que há uma pessoa jurídica respondendo pelo negócio, há separação entre o

patrimônio dos sócios e o patrimônio da sociedade. Além disso, a sociedade existe e é ela que realizará negócios, afastando a possibilidade de alegação de desconhecimento por parte de terceiros.

6.2 Sociedade em conta de participação (art. 991 a 996, CC/2002)

Ainda dentro do gênero sociedades não-personificadas, temos a espécie sociedade em conta de participação. Ela é regulamentada nos art. 991 a 996 do CC/2002 e, ao contrário do que ocorre com a sociedade em comum, sua não-personificação não decorre da ausência de registro, ou registro incorreto, mas de expressa previsão legal.

A lei determina que a sociedade em conta de participação não possui personalidade jurídica própria. Sendo assim, ainda que os sócios a levem a registro, de tal registro não decorrerá a existência de personalidade jurídica própria para a sociedade. De certo que a formalização da sociedade se mostra importante como forma de provar a relação e estabelecer os termos do negócio realizado. Todavia, nunca decorrerá de tal contrato a criação de uma pessoa jurídica autônoma.

Assim, quem se compromete com terceiros, quem negocia com estes, obrigando-se perante a sociedade, é apenas o sócio ostensivo. Ele o faz em seu próprio nome, e não em nome da sociedade em conta de participação. O sócio oculto recebe este nome justamente por permanecer à margem da atividade, permanece escondido da atividade principal. Assim, ele não participa da negociação/contratação nem em nome próprio, nem em nome da sociedade. Seu papel na sociedade é de investidor, sua atuação está relacionada ao financiamento da atividade.

Daí decorre a consequência jurídica de que, perante terceiro, apenas o sócio ostensivo possui responsabilidade, ou seja, caso a atividade se frustre, eventual demanda será promovida apenas em face do sócio ostensivo. A sociedade entre sócio ostensivo e

sócio participante é mesmo irrelevante para terceiros, os quais sequer precisam ter conhecimento do acordo.

Esse tipo de sociedade é muito comum, quando há a vontade de se desenvolver uma atividade empresarial, mas não há recursos financeiros suficientes. Assim, o futuro empresário busca um financiador, todavia, tal pessoa não pretende se envolver na atividade, mas tão somente provê-la dos recursos econômicos necessários.

Vale ressaltar que sócio ostensivo e sócio participante podem ter outras sociedades, não se restringindo à sociedade em conta de participação ao relacionamento entre pessoas físicas. Exemplo disso são os empreendimentos imobiliários nos quais a construtora busca investidores para financiar a obra. A construtora é uma sociedade, geralmente, uma sociedade limitada, e, muitas vezes, os investidores também o são. Mas a relação travada entre a construtora (sócio ostensivo) e o investidor (sócio oculto) constitui uma nova sociedade, não-personificada, que não se confunde com as anteriores – a sociedade em conta de participação.

Caso o empreendimento fracasse, apenas responderá perante terceiros o sócio ostensivo, no nosso exemplo, a construtora. Por óbvio, o sócio participante também terá prejuízos em caso de fracasso, podendo mesmo perder todo o valor investido.

Também temos exemplos de sociedade em conta de participação em empreendimentos menores. Mamede (2018, p. 30-31 e p. 33) nos traz dois exemplos muito elucidativos:

> *"Imagine-se, por exemplo, três serralheiros que ajustem entre si a coparticipação na execução das maiores encomendas. Assim, se A contrata 100 janelas de alumínio, será ele o sócio em posição ostensiva, atuando B e C na posição oculta, trabalhando pela realização do negócio. Quando B contrate 150 portas de alumínio ocupará a posição ostensiva, cabendo aos outros dois, naquele negócio, a posição oculta" . (MAMEDE, 2018, p. 30-31).*

> *“Se Atair, Sueli, Fátima e Helena ajustam entre si que irão trabalhar juntas, produzindo comida árabe para atender à clientela que procura e contrata Sueli (sócia que ocupa posição ostensiva), haverá uma sociedade em conta de participação, mesmo que disso não deem notícia as contratantes”*
>
> *(MAMEDE, 2018, p. 33).*

No primeiro exemplo, a posição de sócio ostensivo, em consequência de sócios ocultos, vai ser ocupada por sócios distintos em cada contrato. Observe, quem realiza a contratação é o serralheiro A, B, ou C. Para o contratante, aquele que encomenda as janelas, ou portas de alumínio, é indiferente o acordo feito entre A, B e C de se ajudarem na produção. Caso sua encomenda venha com defeito, ocorra atraso na entrega, ou a quantidade entregue seja menor do que a contratada, o contratante demandará apenas contra aquele com quem celebrou o contrato. No caso das janelas, contra A, no caso das portas, contra B.

Do mesmo modo, quem responde perante a clientela no segundo exemplo é Sueli, tendo em vista que foi ela quem celebrou contrato com os clientes.

Sociedade simples (art. 997 a 1.038, CC/2002)

Já aprendemos que as sociedades se dividem em sociedades empresariais e sociedades simples. Simples são as sociedades que não exercem atividade empresarial, ou seja, que não constituem elemento de empresa.

Geralmente, serão sociedades simples aquelas formadas, a fim de exercer as atividades elencadas no parágrafo único do art. 966 do CC/2002, ou seja, atividade intelectual, de natureza científica, literária, ou artística. Assim, as sociedades de advogados, de médicos, de dentistas, grupos de teatro, por exemplo, formarão sociedades simples, a menos que o exercício da atividade constitua elemento de empresa.

A constituição dessas sociedades ocorre de modo descomplicado, fazendo jus ao nome. Assim, basta que se leve a registro o contrato social para que se tenha a existência de uma sociedade simples. O registro da sociedade ocorre no Cartório do Registro Civil das Pessoas Jurídicas e o contrato pode ser redigido por instrumento público, ou particular.

Contrato feito por instrumento particular é aquele no qual os sócios deliberam as cláusulas contratuais e eles mesmos, ou alguém por eles contratados, geralmente um advogado, redigem o instrumento, apenas o levando a posterior registro. O contrato feito por instrumento público é aquele elaborado no Cartório de Notas. Neste caso, os sócios se dirigem ao cartório que redigirá os termos contratuais, de acordo com a vontade manifesta dos envolvidos. Com o documento pronto, seja o contrato particular, ou público, devem os sócios levá-lo a registro no Cartório do Registro Civil das Pessoas Jurídicas. Veja que, caso o contrato seja feito por documento público, os sócios irão em dois cartórios distintos, o de Notas, para elaborar o contrato, e o de Registro, para efetivamente registrarem a sociedade.

Não se deve esquecer de que, a depender da atividade desempenhada, haverá a necessidade de se proceder ao registro em mais algum órgão, como no caso da sociedade de advogados, a qual exige registro na OAB.

O contrato social ditará os termos que regerão a sociedade, devendo suas cláusulas mencionarem, no mínimo, os elementos constantes do art. 997 do CC/2002.

Nós já vimos que a constituição de sociedades personificadas tem como uma de suas finalidades separar o patrimônio da sociedade do patrimônio dos sócios, de modo que o patrimônio particular não responda pelas dívidas da sociedade. Todavia, há casos em que, por expressa previsão legal, os sócios responderão com seus patrimônios particulares pelas dívidas da sociedade. É o que ocorre nas sociedades simples.

Os art. 1.023 e 1.024 do CC/2002 estabelecem esta regra ao mencionar que os sócios

responderão pelas dívidas, caso o patrimônio da sociedade seja insuficiente. Gozam tão somente do benefício de ordem, ou seja, primeiro se busca a satisfação no patrimônio da sociedade, para, apenas em caso de este se mostrar incapaz de satisfazer os débitos, buscar-se o patrimônio dos sócios.

Outro aspecto que merece nota é quanto à possibilidade de um dos sócios integralizar sua quota social com serviços. A integralização do capital social é a contribuição que cada sócio dá para o início da sociedade, é a efetiva disponibilização do valor, ou do serviço necessário para o início das atividades.

A divisão da sociedade simples se faz por quotas, divididas entre os sócios da forma que acordarem. Nas sociedades simples, nem sempre a quantidade de quotas pertencentes a cada sócio representará exatamente o valor integralizado. É devido a este fato que é possível um dos sócios integralizar sua quota em serviços.



Por exemplo, imaginemos uma sociedade de advogados, com quatro sócios, cujo capital social inicial é de R$40.000,00 (quarenta mil reais). O sócio A contribuiu com R$20.000,00 (vinte mil reais), o sócio B com R$10.000,00 (dez mil reais), o sócio C com R$10.000,00 (dez mil reais) e o sócio D se incumbiu de formar a carteira de clientes.

Neste exemplo, os sócios podem optar por dividir as quotas, de acordo com os valores investidos por cada um, e aí teriam que atribuir um valor representativo da parte do sócio D, ou poderiam optar por dividir igualmente entre os quatro sócios

Pode parecer estranha a divisão das quotas de modo igualitário entre os sócios, em

vez de a divisão de acordo com o valor efetivamente investido. Todavia, esta possibilidade existe em sintonia com a própria natureza jurídica da sociedade. Muitas vezes, o valor investido não será o mais importante para o desenvolvimento da atividade. No caso apresentado acima, por exemplo, se o sócio D possui uma carreira sólida, é um advogado de renome, e os demais sócios são advogados ainda desconhecidos, em início de carreira, será muito mais vantajoso para a atividade contar com os clientes captados por D do que com os valores investidos pelos demais sócios.

É também em decorrência da natureza da atividade que o CC/2002 (Art. 1.002) determina que não se pode substituir um sócio sem o consentimento dos demais. Em outras palavras, deve-se respeitar a affectio societatis, de modo que nenhum dos sócios seja obrigado a estar em sociedade com quem não tenha expressamente concordado.

Isso significa que o sócio que queira se retirar da sociedade não pode, simplesmente, transferir suas quotas para outra pessoa de sua escolha sem que antes tenha a concordância dos demais sócios. Por outro lado, também não pode ele ser obrigado a permanecer em sociedade. Assim, o direito de retirada (direito de sair da sociedade) pode ser exercido a qualquer tempo, se a sociedade for de prazo indeterminado, o que não pode é o sócio se fazer substituir sem consentimento.

Sociedade limitada (art. 1.052 a 1.087, CC/2002)

Talvez seja a sociedade limitada o tipo societário mais conhecido. É comum observarmos, dos médios aos grandes empreendimentos, a presença da sigla LTDA. A popularização da sociedade limitada deriva da busca pela total distinção entre o patrimônio social e o patrimônio particular dos sócios.

Um dos maiores receios de quem inicia uma atividade empresarial é perder não só os valores e o tempo que investiu, mas também seu patrimônio particular. A existência da sociedade limitada traz, portanto, maior segurança ao sócio, o qual consegue

dimensionar o que está colocando em jogo, sabendo que, via de regra, apenas está arriscando o valor efetivamente investido na sociedade.

O art. 1.052 do Código Civil (2002) estabelece que: “Na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social”. O dispositivo elucida claramente a limitação da responsabilidade dos sócios, ou seja, cada um responderá apenas pelos valores investidos na sociedade.

Esse investimento inicial é chamado de integralização. Para que a sociedade ganhe vida, é necessário que cada sócio cumpra com o acordado entre eles, integralizando sua parte do capital social. Nas sociedades limitadas, essa integralização não pode se dar por serviços, ao contrário do que ocorre nas sociedades simples. Então, para que a sociedade limitada nasça, cada sócio deve efetivamente efetuar o pagamento do valor correspondente a suas quotas.

Caso não o faça, todos os sócios responderão solidariamente pela integralização, ou seja, caso algum sócio deixe de integralizar sua parte, todos os demais terão a mesma responsabilidade de arcar com a parte do sócio faltoso – chamado de sócio remisso.

Esse mandamento tem importância, pois, nem sempre, o capital social será totalmente integralizado no início da atividade. Os sócios podem acordar de integralizar o capital aos poucos. Nesta situação, já estarão atuando enquanto o capital ainda está sendo integralizado. Pode surgir, neste período, alguma demanda em face da sociedade. Neste caso, todos responderão solidariamente pela parcela ainda não integralizada.

> *As quotas deverão ter valor expresso em moeda corrente nacional, obrigatoriamente. O contrato social trará (1) a definição do valor total do capital social (ou capital registrado), (2) o número de quotas em que este estará dividido, obrigatoriamente igual ou superior a duas quotas, (3) o valor de cada quota, que poderá ser igual ou desigual, e (4) a titularidade de cada quota ou*

> *grupo de quotas, relacionando, nominalmente, os sócios (cuja qualificação é exigida pelo artigo 997, I, do Código Civil) e a correspondente participação no capital social. A subscrição do capital social não exige imediata integralização, no ato de assinatura do contrato social ou no ato de seu registro. É lícito especificar tempo e modo para a realização do valor das quotas. Pode-se estabelecer desembolso imediato ou futuro, ainda que em parcelas cujo pagamento será devido no prazo ou termo fixado pelo ato constitutivo. Pode-se estipular, por exemplo, que os sócios integralizarão 40% do valor das quotas sociais no ato da assinatura do contrato, 30% em 12 meses e outros 30% em 24 meses. Nada impede que as condições de integralização sejam distintas para os sócios, se assim dispuser o contrato social, desde que respeitados os princípios gerais do Direito.*
>
> *(MAMEDE, 2018, p. 197)*

A constituição da sociedade limitada se dá através de contrato social, assemelhando-se, nesse sentido, à sociedade simples. Deste modo, o instrumento do contrato também deve obedecer ao que preceitua o art. 997 do CC/2002. A diferença reside no fato de que o registro da sociedade limitada não ocorre no Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas. Em sendo a sociedade limitada, uma sociedade empresária, seu registro deve acontecer na Junta Comercial de sua sede.

As quotas da sociedade limitada podem ter valores diferentes, muito embora essa situação não seja comum. O que se observa, na prática, é a divisão do capital social total em quotas de um real. Assim, uma sociedade cujo capital inicial é de cem mil reais, por exemplo, terá cem mil quotas. O sócio que integralizar vinte mil reais, terá vinte mil quotas da sociedade, e assim sucessivamente.

A participação no capital social – a quantidade e o valor das quotas de cada sócio – será relevante nas deliberações da sociedade, já que as decisões são tomadas por maioria de votos, os quais são contados, de acordo com o valor das quotas de cada sócio, e não com a quantidade de sócios. Sendo assim, um único sócio pode deter o

controle das decisões da sociedade, por ser majoritário.

Dê uma olhada neste vídeo que ensina como registrar a sociedade limitada:

Sociedade anônima (art. 1.088 a 1.089, CC/2002)

A sociedade anônima é o tipo societário mais complexo dentre os estudados. Também é um tipo societário famoso, não é incomum nos depararmos com a sigla S.A. Também não é incomum ouvirmos falar em Bolsa de Valores, Mercado de Capitais, valorização e desvalorização de ações.

Uma sociedade anônima é uma sociedade empresarial constituída para o desenvolvimento de grandes empreendimentos, formada por ações e regida por um estatuto social. Suas normas não estão no Código Civil de 2002, mas na Lei 6404/1976 – Lei das S.A. O CC/2002 previu expressamente que as sociedades anônimas continuariam sendo regulamentadas pela lei específica de 1976.

As sociedades anônimas são deveras complexas e envolvem um emaranhado de relações jurídicas, sendo, por isso, usadas apenas para negócios de grande vulto. Ao contrário da sociedade limitada, a sociedade anônima não se divide em quotas, mas em ações. Cada sócio é titular de ações e pode negociá-las sem a anuência dos demais sócios.

Mas há de se estabelecer uma diferença. Na sociedade anônima de capital aberto, o sócio pode negociar suas ações, valendo-se do Mercado de Capitais. Já a sociedade de capital fechado não pode se valer de tal mercado, ou seja, apenas pode negociar suas ações particularmente.

Existem sócios que apenas adquirem ações de sociedades anônimas com finalidade especulativa, compram aguardando que aquelas ações valorizem, passem a valer mais, portanto, e, depois, vendem-nas novamente no Mercado de Capitais. Mas há uma pequena parcela de sócios que não pretendem se desfazer de suas ações no mercado, são aqueles que efetivamente estejam envolvidos com o desempenho da atividade-fim da sociedade.

As sociedades anônimas são regidas por estatuto. Portanto, não há a elaboração de contrato social no qual os sócios debatem suas cláusulas e chegam a um consenso. Os sócios que ingressarem na sociedade após a sua constituição devem ter conhecimento dos termos do estatuto e estarem de acordo com ele.



Para finalizar, vamos a este apanhado rapidinho e muito elucidativo:

7. Desconsideração da Personalidade Jurídica

Em vários momentos deste tópico, mencionamos a responsabilidade limitada, ou ilimitada dos sócios em cada tipo de sociedade. Vimos que, nas sociedades não-personificadas, bem como na sociedade simples, a sociedade do sócio tende a ser ilimitada – ressalvado o sócio oculto da sociedade em conta de participação.

O instituto da desconsideração da personalidade jurídica tem grande relevância nos casos em que, em regra, a responsabilidade do sócio é limitada, como nas sociedades limitadas e sociedades anônimas. A desconsideração fará com que o patrimônio do sócio passe a responder pelas dívidas da sociedade, mesmo se tal sociedade constituir uma sociedade limitada.

Sociedade anônima (art. 1.088 a 1.089, CC/2002)

Tal situação apenas ocorrerá, quando houver mau uso da figura da sociedade, como, por exemplo, quando há confusão patrimonial entre patrimônio dos sócios e da sociedade, ou quando a pessoa jurídica é usada para fins que não constam do contrato/estatuto social.

A possibilidade de desconsideração está prevista no art. 50 do CC/2002, o qual prevê os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações que serão estendidos aos bens particulares dos administradores, ou sócios da pessoa jurídica, quando houver confusão patrimonial, ou abuso da personalidade jurídica.

Observa-se que a desconsideração ocorrerá em face dos administradores, ou sócios. A interpretação mais adequada que se dá a tal dispositivo legal é no sentido de que apenas responderão os sócios que exercerem a administração da pessoa jurídica, não fazendo sentido, por exemplo, responsabilizar o sócio acionista que sequer tem direito a voto.

Portanto, ainda que certos tipos societários visem a proteger o patrimônio particular de seus sócios, essa proteção não é ilimitada, podendo haver responsabilização em caso de desvirtuamento no desempenho da atividade.

8. Conclusão

Este tópico teve a intenção de apresentar os principais aspectos relativos ao Direito Societário.

Intentou-se demonstrar que a atividade lucrativa, constitua ela elemento de empresa, ou não, pode ser exercida por uma pessoa sozinha, ou em sociedade. Logo, optando-se por exercer a atividade em sociedade, deve-se respeitar as regras estabelecidas na legislação.

Vimos as principais distinções atinentes à matéria, bem como os principais tipos societários – os mais conhecidos e de maior relevância prática no dia a dia da maioria das profissões.

Por fim, vimos que, muito embora haja meios de se separar a responsabilidade pela atividade societária dos bens particulares, há de se ter muita atenção, pois, em caso

de atuação que desvirtue a atividade, o patrimônio particular poderá ser atingido através da desconsideração da personalidade jurídica.

Faça bom uso da lição, bem como de todos os recursos presentes neste tópico.

Bons estudos!

9. Referências

BRASIL. Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406compilada.htm.

CHAGAS, Edilson Enedino das. Direito Empresarial Esquematizado. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2017.

COELHO, Fábio Ulhoa. Manual de Direito Comercial: Direito de Empresa. 28. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016.

MAMEDE, Gladston. Direito Empresarial Brasileiro: Direito Societário – Sociedades simples e empresárias. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2018.

YouTube. (2011). Fundação Parque Tecnológico da Paraíba. Passo a passo para abrir uma empresa. 4min58. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=6dnTYssluiA.

YouTube. (2018). Sebrae. Como registrar uma empresa LTDA. 2min34. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=vjytQFcxH7g.

YouTube. (2016). Leonardo Hoffmam. Sociedade Anônima: características e diferenças capital aberto e capital fechado. 10min06. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=5kl8Nok-JOU

Parabéns, esta aula foi concluída!

O que achou do conteúdo estudado?



Péssimo Ruim Normal Bom Excelente

Deixe aqui seu comentário

Mínimo de caracteres: 0/150

Enviar